일감법학 | 제51호
2022년 4월 283-316쪽
건국대학교 법학연구소

Ilkam Law Review
Vol.51, Apr., 2022. pp.283-316
The Institute of Legal Studies, Konkuk Univ.

사형제의 쟁점 및 개선방향

Issues and Improvement Direction of the Death Penalty

이 희 훈*
Lee, Hie-Houn

목 차

Ⅰ. 들어가는 말
Ⅱ. 사형의 의미와 우리나라의 사형제 존폐 여론의 실태
Ⅲ. 사형제에 대한 미국과 일본의 주요 판례들의 중요 내용
Ⅳ. 사형제에 대한 합헌론과 위헌론의 사유나 근거
Ⅴ. 맺는 말

사형제는 다음과 같이 크게 네 가지 점에서 위헌성이 높다.

첫째, 근대 형법에서는 형벌의 응보 효과와 일반예방 효과 및 특별 예방효과가 있어야 한다. 그러나 사형제는 극악한 중범죄인의 생명을 박탈하여 형벌의 특별 예방효과가 없고, 사형수의 생명권을 영구히 박탈하는 등의 사유로 헌법상 인간의 존엄성에 저촉되어 위헌성이 높다.

둘째, 우리 헌법 제110조 제4항 단서 조항은 사형제의 심각성을 강조하려는 것으로, 이 법 규정을 사형제를 인정하는 규정으로 보는 것은 타당성이 희박하다.

셋째, 사형제에 의한 형벌의 일반 예방효과는 실증할 수가 없으며, 사형제 대신에 절대적 종신형 제도나 상대적 종신형 제도라는 대체 수단을 통해서 형벌의 일반 예방효과나 특별 예방효과를 행할 수 있으므로, 사형제는 헌법상 비례의 원칙에 저촉되어 위헌성이 높다.

넷째, 사형제는 오판의 가능성이 있으므로 위헌성이 높다.

https://doi.org/10.35148/ilsilr.2022..51.283
투고일: 2022. 3. 15. / 심사완료일: 2022. 3. 29. / 게재확정일: 2022. 4. 22.

* 선문대학교 법・경찰학과 정교수, 법학박사
Full Professor of Law and Police at SunMoon University

www.kci.go.kr

그러나 2003년과 2018년에 국가인권위원회에서 우리 국민들에게 실시한 사형제의 존폐 여부에 대한 설문조사에 의하면 각각 약 66% 및 80%의 다수의 국민들은 사형제가 유지되기를 바라는 것으로 나타났다. 이에 비추어 볼 때, 국민주권국가에서 민주주의 원리의 보장과 실현을 위해서, 현재 국회에 계류 중인 의안번호 2112795번의 이상민 국회의원이 대표 발의한 사형 폐지에 관한 특별법안에 의하여 사형제를 일체 전면적으로 폐지한 후에 이른바 '절대적 종신형'제도로 모두 대체하는 급진적인 형태의 개선방향 보다는 향후 국회에서 형법 등의 관련 법 규정들에서 사형을 부과할 수 있는 범죄의 종류를 적절한 범위로 한정하여 제한하는 등 사형 대상 범죄의 종류들을 점진적으로 축소해 나가는 것이 바람직하다.

그리고 국회는 이렇게 먼저 사형제에 대하여 개선한 후에 향후에 우리 국민들의 과반수 이상의 다수가 사형제의 폐지에 대하여 긍정적인 여론이 형성이 되고 공감대를 얻게 되었을 때, 사형제의 폐지에 대한 대체 형벌의 수단으로 극악한 중범죄인에게 형벌의 특별예방효과가 여전히 없는 '절대적 종신형'제도의 형태보다는 해당 중범죄인에게 최소 30년부터 최대 50년간 교도소에서 복역하도록 한 후에 개전의 정이 명백할 경우 등의 매우 엄격하고 까다로운 여러 실체적・절차적인 요건들에 의하여 가석방이 가능할 수 있도록 하는 '상대적 종신형'제도를 시행하는 방향으로 적절하게 개선하는 것이 바람직하다.

또한 독일처럼 상대적 종신형을 선고 받은 해당 중범죄인에게 만약 가석방을 해줄 경우에는 법무부가 아닌 법원의 판단에 의하여 예를 들어, 5년 이하의 상당한 기간 동안 보호관찰과 전자발찌 등의 전자 감시나 전자 통제 장치를 필수적으로 함께 부과하는 형태로 개선하는 것이 바람직하다.

[주제어] 사형제, 응보 효과, 일반 예방효과, 특별 예방효과, 비례의 원칙, 절대적 종신형, 상대적 종신형, 인간의 존엄과 가치, 오판

Ⅰ. 들어가는 말

최근 2022년 3월 9일에 우리나라에서는 제20대 대통령 선거가 있었는바, 윤석열 제20대 대통령 당선인은 2022년 2월 23일에 실시한 국제엠네스티 한국지부가 공개한 7대 인권 의제에 대한 대선 후보 질의에 대한 답변서에서 "완전한 사형제의 폐지는 사회의 성숙한 합의가 필요하다."며 사형제의 폐지를 추진하지 않는다고 밝혔다.[1)]

1) 서울경제, "사형제 폐지에…이재명 찬성 vs. 윤석열 반대", <https://www.sedaily.com/NewsView/26294I TSBW>, 검색일: 2022.3.10. 이전의 문재인 대통령은 사형제에 대한 폐지 입장을 밝혔고, 또 그 이전의 박근혜 대통령은 사형제에 대하여 찬성의 입장을 밝혔다. 조선일보, "박근혜 사형제도, 흉악범에 경고 효과, 문재인 등 민주당 후보들 사형제 폐지", <http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2012/09/05/2012090500145.html>, 검색일: 2022.3.10.

www.kci.go.kr

최근 우리나라에서는 2021년 12월 21일에 이미 강도 살인 등으로 무기징역형을 선고받고 복역 중인 20대인 이 모씨가 같이 수감 중인 공주교도소의 수용실 안에서 동료 재소자인 A씨를 마구 때려 또 살인을 저질렀다. 이에 검찰은 다른 사람의 생명을 빼앗고도 또 살인을 저지른 이 모씨의 살인행위에 대해서 사형을 구형할 것으로 전해졌는바, 이로 인하여 다시 우리 사회에서 사형제에 대한 존폐 여부에 대한 논란이 일어날 것으로 전망된다.[2] 이처럼 그동안 우리나라에서 울산 자매 살인범인 김O일 사건, 수원 여대생 토막살인범인 오O춘 사건, 경기도 서남부 일대 여성 연쇄살인범인 강O순 사건, 부산 여중생 납치살인범인 김O태 사건 등과 같이 잔혹한 강력 살인 범죄들이 발생할 때마다 사형제의 존폐 여부에 대한 논란이 지속되어 왔다. 이에 대하여 현재 제21대 국회에는 2021년 10월 7일에 더불어민주당의 이상민 국회의원이 대표로 총 30명의 국회의원들이 의안번호 2112795번으로 '사형 폐지에 관한 특별법안'이 법제사법위원회에 계류되어 있다.

한편 이러한 사형제에 대하여 우리나라는 지난 1997년 12월 30일에 23명의 사형수에 대한 사형을 집행한 이후에 약 25년째 사형을 시행하지 않고 있어서, 국제엠네스티에서 2007년 12월 30일에 우리나라를 세계 134번째로 '실질적 사형폐지국가'로 분류하고 있다. 그리고 우리 정부는 지난 2009년에 유럽평의회(Council of Europe)의 회원국 및 기타 국가 간의 형사사법공조협약 및 범죄인인도협약에 가입하였는바, 본 협약에 가입한 유럽연합(EU) 회원국 전체를 비롯한 47개의 유럽국가 및 이스라엘, 남아프리카공화국 등의 국가로부터 인도된 범죄인에 대해서는 대한민국 법원이 사형을 선고하더라도 그 형을 집행할 수 없게 되어 있다.[3]

이렇듯 우리나라를 포함한 많은 전 세계 국가들에서 끊임없이 그 존치와 폐지 여부에 대하여 끊임없이 논란이 되고 있는 사형제에 대하여 이하에서는 각각 다음과 같은 순서로 자세히 살펴본다. 먼저 사형의 의미와 국가인권위원회에서 행한 지난 2003년과 최근 2018년에 각각 행한 우리나라 국민의 사형제 존폐에 대한 여론조사 결과의 통계자료상의 변화에 대하여 살펴본다(이하 Ⅱ). 다음으로 사형제를 현재 행하고 있는 대표적인 국가인 미국 연방대법원과 일본 최고재판소의 사형제에 대한 주요 판례들의 주요 내용들 및 이에 대한 우리나라에의 시사점을 고찰한다(이하 Ⅲ). 그리고 사형제에 대한 합헌론과

2) 문화일보, "살인범이 복역 중 또 살인…대선서 사형제 존폐 논쟁 촉발", <http://www.munhwa.com/news/view.html?no=20220206MW075442347046>, 검색일: 2022.3.10.

3) 의안번호 2112795번의 이상민 국회의원이 대표로 발의한 '사형 폐지에 관한 특별법안'의 제안 이유 부분 참조.

www.kci.go.kr

위헌론의 여러 사유나 근거들에 대하여 각각 살펴본 후, 이에 대한 헌법적 및 입법 정책적인 검토를 한다(이하 Ⅳ). 끝으로 결론 부분인 맺는 말 부분에서는 Ⅱ-2번에서 살펴본 사형제의 존폐 여부에 대한 우리나라 여론조사의 결과에 비추어, 2022년 3월 현재 국회에 계류 중인 의안번호 2112795번의 '사형 폐지에 관한 특별법안'의 내용을 포함하여 향후 우리나라의 사형제에 대한 존폐 여부 및 만약 우리나라에서 향후 사형제의 존치 및 폐지 시 여러 바람직한 개선방향들을 제시한다(이하 Ⅴ).

Ⅱ. 사형의 의미와 우리나라의 사형제 존폐 여론의 실태

1. 사형의 의미

형법 제41조 제1호에서는 "형의 종류는 다음과 같다. 1. 사형"이라고 규정하여, 형벌의 종류의 하나로서 사형에 대하여 규정하고 있다. 이러한 사형은 인간존재의 바탕인 범죄자의 생명을 빼앗아 사람의 사회적 존재를 말살하는 형벌에 해당한다는 점에서 생명형임과 동시에 성질상 모든 형벌 중에서 가장 무거운 형벌에 해당하므로 극형에 해당되는 최고의 형벌이다. 이러한 사형은 인류의 역사상 가장 오래된 역사를 가진 형벌의 하나로서, 사형은 범죄에 대한 근원적인 응보의 방법이며,[4] 가장 효과적인 일반 예방법으로 사람들 사이에서 인식되어 왔는바, 우리나라에서 사형제도는 고조선의 소위 8조금법(八條禁法)에서 '상살자 이사상(相殺者 以死償)'이라고 규정된 것에서부터 그 기원을 찾을 수 있고, 현재는 형법과 군형법 등 여러 특별 형법에서 가장 극형으로 인정되어 왔다.[5]

즉, 사형이란 국가가 사형으로 처벌될 범죄의 구성요건에 해당하는 중범죄를 저지른 해당 범죄인의 생명을 인위적으로 영구히 제거 또는 박탈하는 형벌이라는 점에서, 사형은 생명형에 해당하면서 극형에 속하며, 자연사와 대비된다.

4) 범죄와 형법 간의 칸트의 응보원리에 의한 사형제의 자세한 것은 손미숙, "살인을 했다면 그는 죽어야 한다. -칸트와 형법-", 법철학연구 제14집 제3호, 한국법철학회, 2011, 207-228쪽.

5) 헌법재판소 1996. 11. 28. 선고 95헌바1 결정.

www.kci.go.kr

2. 우리나라의 사형제 존폐 여론의 실태[6)]

우리나라에서 사형제의 존폐 여부에 대하여 지난 2003년에 국가인권위원회에서 일반 국민을 대상으로 한 전화여론조사의 결과에 의하면, 사형제의 존치의견이 65.9%로 나타났는바, 이 중에서 사형제는 반드시 유지되고 강화되어야 한다는 의견은 8.3%, 사형제는 유지되어야 하지만 사형선고나 그 집행은 신중히 해야 한다는 의견은 57.6%로 나타났다.

그리고 같은 설문조사에서 사형제의 폐지의견이 34.1%로 나타났는바, 이 중에서 사형제는 즉시 당장 폐지되어야 한다는 의견은 13.2%, 사형제는 언젠가 폐지되어야 한다는 의견은 20.9%로 나타났다.

한편 최근 2018년에 국가인권위원회에서 리얼미터에 의뢰한 지역별・연령별・성별 비례할당에 의한 일반 국민 약 1,000명을 대상으로 온라인 설문조사의 결과에 의하면, 사형제의 존치의견이 79.7%로 나타났는바, 이 중에서 사형제는 반드시 유지되고 강화되어야 한다는 의견은 19.9%, 사형제는 유지되어야 하지만 사형선고나 그 집행은 신중히 해야 한다는 의견은 59.8%로 나타났다.

그리고 같은 설문조사에서 사형제의 폐지의견이 20.3%로 나타났는바, 이 중에서 사형제는 즉시 당장 폐지되어야 한다는 의견은 4.4%, 사형제는 언젠가 폐지되어야 한다는 의견은 15.9%로 나타났다.

이렇듯 지난 2003년과 최근 2018년의 2개의 국가인권위원회에서 행한 우리나라 국민을 대상으로 실시한 사형제의 존폐 여부에 대한 여론조사의 결과를 비교하여 살펴보면, 우리나라에서 '사형제는 유지되어야 하지만 사형선고나 그 집행에 신중히 해야 한다.'는 의견과 '사형제는 반드시 유지・강화되어야 한다.'는 의견은 각각 2.2%와 11.6%로 증가한 반면에, 우리나라에서 사형제를 '즉시 당장 폐지해야 한다.'는 의견과 '당장은 아니지만 언제가 폐지되어야 한다.'는 의견은 각각 8.8%와 5.0%로 감소한 것으로 분석되었다.[7)]

---

6) 한영수/이진국/이덕인/김도우/이자영, "사형제도 폐지 및 대체형벌 실태조사", 2018년 인권상황실태조사 연구용역보고서, 국가인권위원회, 2018. 10, 140-141쪽.

7) 참고로, 지난 2009년 12월에 여론조사기관인 리얼미터에서 전국 19세 이상 남녀 약 1,000명을 대상으로 전화여론조사의 결과에 의하면, 사형제의 존치의견이 66.7%, 사형제의 폐지의견이 21.5%로, 사형제에 대한 존치나 찬성 의견이 약 3배 정도 높은 것으로 나타났다. 이 당시 흉악범죄가 우리 사회에서 증가한 것에 대한 국민들의 불안감이 증폭되는 등의 심리적인 요인이 사형제의 존치나 찬성 의견에 영향을 준 것으로 분석된다. 경향닷컴, "사형제도 유지해야, 여론 오히려 늘었다", <https://www.khan.co.kr/national/national-general/article/200912160956191>, 검색일: 2022.3.10.

www.kci.go.kr

Ⅲ. 사형제에 대한 미국과 일본의 주요 판례들의 중요 내용

1. 사형제에 대한 미국 연방대법원의 주요 판례들의 중요 내용

1.1 사형제 자체에 대한 미국 연방대법원의 주요 위헌 판례의 중요 내용

흑인 Jackson은 백인 여성을 강간한 죄로 미국의 조지아 주 법원에서 사형을 선고받았고, 흑인 Furman은 집주인을 죽인 죄로 미국의 조지아 주 법원에서 사형을 선고 받았으며, 흑인 Branch는 백인 여성을 강간한 후에 타인에게 이러한 사실을 알리면 죽이겠다고 협박을 한 죄로 미국의 텍사스 주 법원에서 사형선고를 받았다.

이에 대하여 미국 연방대법원 판사들 중 스튜어트(Stewart), 화이트(White), 더글라스(Douglas), 브레넌(Brennan), 마살(Marshall) 대법관 5명은 법정 의견으로, "사형은 미국 연방수정헌법 제8조[8]와 제14조[9]에 위반되는 잔혹하고 비정상적인 형벌에 해당하여 위헌이다."라고 판시하였다. 이 중에서 대표적으로 더글라스 미국 연방대법원 대법관은 입법적으로 범죄인에게 사형을 선고를 할 수 있는 명확한 제한 내지 근거 기준이 없거나 또는 그 근거 규정의 기준이 명확하지 않아서, 법원의 재판관이나 또는 배심원들의 자의적인 판단에 의하여 사형이 부과될 수 있다는 점에서, 결국에 사회적 지위가 높지 않거나 경제적으로 풍족하지 않은 가난하고 사회적으로 약자인 사람이나 흑인에게 좀 더 사형이 쉽게 선고되는 경향을 보이게 된다는 점에서 사형은 잔혹하고 비정상적인 형벌에 해당하므로, 사형은 미국 연방수정헌법 제8조와 제14조에 반하는 위헌적 형벌이라는 의견을 제시하였다.[10]

---

8) 미국 연방수정헌법 제8조에서는 "과다한 보석금을 요구하거나, 과다한 벌금을 과하거나, 잔혹하고 비정상적인 형벌을 과하지 못한다."라고 규정하고 있다.

9) 미국 연방수정헌법 제14조에서는 "제1절: 미국에서 출생하고 또는 귀화하고, 미국의 관할권에 속하는 모든 사람은 미국 및 그 거주하는 주의 시민이다. 어떠한 주도 미국 시민의 특권과 면책권을 박탈하는 법률을 제정하거나 시행할 수 없다. 어떠한 주도 정당한 법의 절차에 의하지 아니하고는 어떠한 사람으로부터도 생명, 자유, 또는 재산을 박탈할 수 없으며, 그 관할권 내에 있는 어떠한 사람에 대하여도 법률에 의한 동등한 보호를 거부하지 못한다."라고 규정하고 있다.

10) *Furman v. Georgia*, 408 U.S. 238 (1972).

www.kci.go.kr

1.2 사형제 자체에 대한 미국 연방대법원의 주요 합헌 판례의 중요 내용

미국 연방대법원이 위처럼 1972년에 *Furman v. Georgia* 판결에서 사형제에 대하여 위헌으로 판시[11]한 다음에 미국의 조지아 주, 플로리다 주, 텍사스 주, 노스캐롤라이나 주 및 루이지애나 주에서는 사형제가 잔혹하고 비정상적인 형벌이 되지 않도록 사형을 선고할 수 있는 여러 근거 기준들에 대하여 사형제와 관련된 법 규정들을 개정하였다. 그리고 Troy Leon Gregg(그레그)는 1973년에 2명에게 무장 강도와 살인을 한 죄로 미국의 조지아 주 법원에서 사형을 선고받았는바, 미국의 조지아 주의 법에 의하면 배심원들에게 해당 피고인에게 여러 형의 감경 사유들과 가중 사유들을 고려하도록 규정하였고, 매우 국한된 범죄에 한해서만 피고인에게 사형을 부과할 수 있도록 규정하였다. 그리고 동 법 규정에서 사형을 부과하는 사건에 대해서는 공판절차를 이분화하도록 규정하였고, 미국의 조지아 주의 대법원에 자동적으로 상소가 이루어지도록 규정하였다. 이러한 점에 의하여 7명의 미국 연방대법원의 대법관들은 "사형은 그 자체가 잔혹하고 비정상적인 형벌이 아닌바, 미국의 조지아 주의 법은 배심원들이 사형 부과 시 해당 피고인의 성격과 범행의 여러 정황들을 참작하도록 규정하여 배심원들이 자의적으로나 또는 불규칙적으로 사형을 부과하는 것을 충분히 방지하도록 규정하고 있으므로, 미국 연방수정헌법 제8조와 제14조에 저촉되지 않아 그레그에 대한 사형선고는 합헌이다."라고 판시하였다.[12] 다만 이 판례에서 7명의 미국 연방대법원의 대법관들은 자의적이거나 불규칙적인 모든 사형의 부과는 위헌이며, 이 판례에 의하여 미국의 모든 주의 사형제에 대한 법 규정들이 자동적으로 합헌이 되는 것은 아니라고 본 점은 각별히 주의해야 한다.[13]

1.3 기타 사형제의 쟁점에 대한 미국 연방대법원의 여러 주요 위헌 판례들의 중요 내용

먼저 미국 연방대법원은 1976년에 *Gregg v. Georgia* 판결에서 사형제 자체에 대하여 합헌으로 판시한 이후에 *Coker v. Georgia* 판결에서 살인을 수반하지 않은 강간범에 대하여 사형을 부과하는 것은 범죄와 불균형을 이루어 사형이 잔혹하고 비정상적인

11) *Furman v. Georgia*, 408 U.S. 238 (1972).

12) *Gregg v. Georgia*, 428 U.S. 153 (1976).

13) Carmen, Rolando V.del, 최석윤 옮김, "사형에 관한 미국 연방대법원의 판례", 형사정책연구 제10권 제1호, 한국형사정책연구원, 1999, 168쪽.

www.kci.go.kr

형벌이 된다는 점에서 위헌이라고 판시하였다.[14)]

다음으로 미국 연방대법원은 *Enmund v. Florida* 판결에서 공범으로서 중죄살인의 유죄판결을 받은 피고인이 직접 살인을 행하지 않거나 살인을 의도하지 않았거나 치명적인 폭력의 행사를 의도하지 않았을 경우에 그 공범으로서 중죄살인의 유죄판결을 받은 피고인에게 사형을 부과하는 것은 위헌이라고 판시하였다.[15)]

그리고 미국 연방대법원은 *Atkins v. Virginia* 판결에서 정신적으로 지능발달이 늦은 지적장애인인 피고인에게 사형을 부과하는 것은 미국 연방수정헌법 제8조에 저촉되어 위헌이라고 판시하였다.[16)]

또한 미국 연방대법원은 *Roper v. Simmons* 판결에서 18세 이하의 청소년 피고인에게 사형을 부과하는 것은 위헌이라고 판시하였다.[17)]

2. 사형제에 대한 일본 최고재판소의 주요 합헌 판례들의 중요 내용

2.1 1948년 3월 12일의 일본 최고재판소의 사형제의 합헌 판례의 중요 내용

일본 최고재판소는 1948년 3월 12일에 사형제에 대하여 “생명은 존귀한 것으로 한 사람의 생명은 전 지구보다도 중요하다. 다만 사형은 모든 형벌 중에서 가장 냉엄한 형벌이며 정말 어쩔 수 없을 때에 부과할 수 있는 형벌이다. 왜냐하면 사형은 존엄한 인간존재의 근원인 생명 그 자체를 영원히 박탈하는 것이기 때문이다. 이에 따라 일본 헌법 제13조에서 모든 국민은 개인으로서 존중되며 생명에 대한 국민의 권리에 대하여 최대한 존중해야 한다고 규정하고 있다. 그러나 동시에 일본 헌법 제13조에서 공공의 복지라는 기본적 원칙에 반할 때에는 생명에 대한 국민의 권리이더라도 입법상 제한이나 박탈을 할 수 있다고 할 것인바, 국민 개인의 생명이더라도 법률이 정한 적법의 절차에 따라 이러한 생명을 박탈하는 형벌을 부과할 수 있다고 할 것이다. 다만 사형을 집행하는 데 있어 화형, 책형(창으로 찔러 죽이는 형벌), 효수(목을 잘라 죽이는 형벌), 부탕(펄펄 끓는 가마솥에 넣어 죽이는 형벌) 등의 여러 잔혹 또는 잔인한 방법을 통하여 사형을 집행하도록 규정한 법률이 있다면 그 해당 법률은 일본 헌법 제36조에 반한다고 할

14) *Coker v. Georgia*, 433 U.S. 584 (1977).

15) *Enmund v. Florida*, 458 U.S. 782 (1982).

16) *Atkins v. Virginia*, 536 U.S. 304 (2002).

17) *Roper v. Simmons*, 543 U.S. 551 (2005).

www.kci.go.kr

것이다."라고 판시하였다.[18)]

2.2 1948년 8월 18일의 일본 최고재판소의 사형제의 합헌 판례의 중요 내용

일본 최고재판소는 1949년 8월 18일에 사형제에 대하여 "사형은 일본 헌법 제31조에 의해 시인할 수 있고, 일본 헌법 제36조에 의한 잔혹 또는 잔인한 형벌에 해당하지 아니한 바, 사회를 구성하는 개인의 생명과 인격 등의 존중은 자기뿐만 아니라 타인에게도 같아야 하는 것으로, 일본 헌법 제13조에서 '모든 국민은 개인으로서 존중된다. 생명과 자유 및 행복추구에 대한 국민의 권리에 대해서는 공공의 복지에 위반되지 않는 한 입법 및 기타 국정상 최대한의 존중을 필요로 한다.'라고 규정하여 누구나 자기나 타인 모두 이 규정을 준수해야 한다고 요구하고 있다. 따라서 타인의 생명을 존중하지 않고 고의로 타인의 생명을 침해한 자에게 자기의 행위에 대해 자기의 생명을 잃어야 할 형벌에 처해 질 책임을 부담해야 하는 것이다."라고 판시하였다.[19)] 이렇듯 일본의 최고재판소는 사형을 규정한 형법 등의 관련 규정들은 합헌임을 재차 거듭 판시하였는바, 이러한 일본 최고재판소의 사형제에 대한 합헌의 입장이나 태도는 현재까지 계속 변함없이 이어져 오고 있다.

3. 검토

2020년 4월에 국제엠네스티가 전 세계의 사형제 현황을 담은 '연례사형보고서'에서 전 세계 국가들의 사형제의 존폐 여부에 대한 조사 결과에 의하면, 전 세계 국가들의 입법적으로 명백하게 사형제를 폐지하거나 또는 우리나라처럼 아직 입법적으로 사형제를 폐지하지는 않았지만 10년 이상 사형을 집행하지 않아서 사실상 사형폐지국에 해당하여 실질적인 사형폐지국에 해당되는 국가들은 144개국으로 나타났다. 그리고 이 중에서 모든 범죄들에 대하여 사형제를 폐지한 국가로는 108개국으로 나타났다. 다만, 나머지 약 18%인 36개의 미국의 일부 주 및 중동 지역과 아시아 지역 및 아프리카 지역의 일부 국가들에서 아직 사형제를 입법적으로 존치하면서 실제로 사형을 집행도 하고 있는

18) 日最判, 昭 23. 3. 12, 刑集 2. 3, 191쪽. 이에 대하여 자세한 것은 김영옥, "사형제도에 관한 판례연구", 형사법연구 제8호, 한국형사법학회, 1995, 68쪽.

19) 日最判, 昭 24. 8. 18, 刑集 3. 9, 1478쪽. 이에 대하여 자세한 것은 김영옥, 위의 논문, 69쪽.

www.kci.go.kr

것으로 나타났다.[20]

이렇게 현재까지 사형제를 존치하고 사형을 행하고 있는 여러 국가들 중에서 대표적으로 미국의 연방대법원과 일본 최고재판소의 사형제에 대한 주요 판례들로부터 우리나라에 미치는 시사점들에 대하여 살펴보면, 먼저 위의 Ⅲ-1번에서 살펴본 것처럼, 미국의 상당수의 주(州) 법원에서 재판관 등이 범죄인에게 사형을 선고할 때 그 재량권을 남용하여 자의적인 기준에 의하여 제멋대로 변덕스럽게 사형을 부과할 수 없도록 사형을 행할 수 있는 판단의 기준이 되는 형의 감경 사유 및 가중사유를 어떤 기준에 의해 결정할 수 있는지에 대한 여러 규정들을 상세히 구체적으로 마련하는 것, 예를 들어 누가 사형에 처해 지고 누가 무기징역에 처해 질 것인가를 명문의 기준에 의하여 결정할 수 있게 하는 등의 상세하고 구체적인 여러 규정들에 대한 이중적 심리절차조항 등을 새롭게 마련하는 것[21] 등에 대하여 우리나라가 계속해서 사형제를 입법적으로 존치할 경우에는 참고할 점이라는 것을 시사해 준다.

그리고 위의 Ⅲ-1번에서 미국 연방대법원의 사형제에 대한 여러 주요 판례들의 주요 내용들을 살펴본 것에 비추어 볼 때, 강간범이나 방조범 또는 지적장애자인 범죄인이나 18세 이하의 미성년자인 범죄인 등 일정한 종류의 범죄자에게는 사형을 행하지 않도록 하는 것에 대하여 우리나라가 계속해서 사형제를 입법적으로 존치할 경우에는 참고할 점이라는 것을 시사해 준다.

또한 위의 Ⅲ-2번에서 일본 최고재판소의 사형제에 대한 여러 주요 판례들의 주요 내용들을 살펴본 것에 비추어 볼 때, 범죄자를 포함한 모든 인간들의 생명권은 매우 소중하므로 최대한 보장해 주어야 하지만, 일본 헌법에서의 공공의 복지, 즉, 우리나라 헌법 제37조 제2항에 의하면 국가안전보장이나 질서유지를 위하여 사형이라는 형벌 그 자체는 예외적으로 필요 최소한의 범위 내에서 가능하지만, 사형의 집행 방법이 인간의 존엄에 저촉되는 잔혹하거나 잔인한 사형의 방법을 사용해서는 안 된다는 것에 대하여 우리나라가 계속해서 사형제를 입법적으로 존치할 경우에는 참고할 점이라는 것을 시사해 준다.

---

20) 국제엠네스티, “2020년 전세계 사형 현황을 담은 <연례사형보고서> 발표”, <https://amnesty.or.kr/40995/>, 검색일: 2022.3.10.

21) 박용철, “미국의 사형제도 개괄”, 비교형사법연구 제12권 제1호, 한국비교형사법학회, 2010, 343쪽: 오영근, “미국의 사형제도”, 법학 제54・55호(합본), 서울대 법학연구소, 1983, 297쪽.

www.kci.go.kr

Ⅳ. 사형제에 대한 합헌론과 위헌론의 사유나 근거

1. 사형제에 대한 합헌론의 사유나 근거

사형제에 대하여 합헌으로 보는 견해는 대체로 크게 다음과 같이 다섯 가지의 사유나 근거들을 제시하고 있다.

1.1 헌법상 사형제를 인정하는 규정이 있는 점

우리나라 헌법 제12조 제1항에서 "모든 국민은 … 법률과 적법절차에 의하지 아니하고는 처벌・보안처분 또는 강제노역을 받지 아니한다."라고 규정하고 있는바, 이 규정에서 처벌에 관한 규정을 법률에 위임하였을 뿐 그 처벌의 종류를 제한하지 않고 있고,[22] 헌법 제110조 제4항에서 "비상계엄 하의 군사재판은 군인・군무원의 범죄나 군사에 관한 간첩죄의 경우와 초병・초소・유독음식물공급・포로에 관한 죄 중 법률이 정한 경우에 한하여 단심으로 할 수 있다. 다만, 사형을 선고한 경우에는 그러하지 아니하다."라고 규정하고 있다. 이는 법률에 의하여 사형이 형벌로서 규정되고, 그 형벌조항의 적용으로 사형이 선고될 수 있음을 전제로 하여, 사형을 선고한 경우에는 비상계엄 하의 군사재판이라도 단심으로 할 수 없고, 사법절차를 통한 불복이 보장되어야 한다고 해석된다. 따라서 우리나라 헌법은 이러한 헌법 규정들의 해석상 사형제를 간접적으로 인정하고 있다고 보아야 할 것이기 때문에 사형제는 합헌이라는 의견을 제시하고 있다.[23]

1.2 사형제는 헌법상 비례의 원칙에 위반되지 않는 점

우리나라 헌법은 절대적 기본권을 명문으로 인정하지 않고 있는바, 헌법 제37조 제2항에서는 국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장・질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있도록 규정하고 있으므로, 어느 개인의 생명권에 대한 보호가 곧바로 다른 개인의 생명권에 대한 제한이 될 수밖에 없거나 또는

22) 대법원 1963. 2. 28. 선고 62도241 판결; 대법원 1987. 9. 8. 선고 87도1458 판결; 대법원 1990. 4. 24. 선고 90도319 판결; 대법원 1994. 12. 19. 선고 94초123 판결.

23) 헌법재판소 1996. 11. 28. 선고 95헌바1 결정.

www.kci.go.kr

특정한 인간에 대한 생명권의 제한이 국민의 생명 보호나 이에 준하는 매우 중대한 공익을 지키기 위하여 불가피한 경우에는 비록 생명이 이념적으로 절대적 가치를 지닌 것이더라도 생명에 대한 법적 평가가 예외적으로 허용될 수 있다고 할 것이어서, 생명권 역시 헌법 제37조 제2항에 의한 일반적 법률유보의 대상이 될 수밖에 없다.[24)]

즉, 정당한 이유 없이 타인의 생명을 부정하거나 그에 못지아니한 중대한 공공이익을 침해한 경우에 국법은 그중에서 타인의 생명이나 공공의 이익을 우선하여 보호할 것인가의 규준을 제시하지 않을 수 없으므로, 생명권 역시 헌법 제37조 제2항에 의한 일반적 법률유보의 대상이 될 수밖에 없다 할 것이며, 생명권에 대한 제한은 곧 생명권의 완전한 박탈을 의미한다고 할 것이어서 사형이 비례의 원칙에 따라서 최소한 동등한 가치가 있는 다른 생명 또는 그에 못지아니한 공공의 이익을 보호하기 위한 불가피성이 충족되는 예외적인 경우에만 적용되는 한, 그것이 비록 생명을 빼앗는 형벌이라 하더라도 헌법 제37조 제2항 단서에 위반되는 것으로 볼 수 없다.[25)] 그리고 사형제가 헌법상 비례의 원칙[26)]에 위반되는지에 대해 살펴보면 다음과 같은 여러 사유들로 위반되지 않아 사형제는 합헌이라는 의견을 제시한다.[27)]

첫째, 다른 사람의 생명을 부정하는 등의 극악한 중범죄에 대한 불법적 효과로서 지극히 한정적인 경우에만 부과되는 사형은 죽음에 대한 인간의 본능적인 공포심과 범죄에 대한 응보욕구가 서로 맞물려 고안된 '필요악'으로서 불가피하게 선택된 것인바, 지금도 여전히 제 기능을 하고 있다는 점에서 그 목적이 정당화될 수 있다.[28)] 즉, 사형은 이를 형벌의 한 종류로서, 국민에 대한 심리적 위하를 통하여 범죄의 발생을 예방하며, 이를 집행함으로써 극악한 범죄에 대한 정당한 응보를 통하여 정의를 실현하고, 당해

24) 헌법재판소 2010. 2. 25. 선고 2008헌가23 결정에서 헌법재판소 재판관 5인의 합헌 의견 부분 참조.

25) 헌법재판소 1996. 11. 28. 선고 95헌바1 결정에서 헌법재판소 재판관 7인의 합헌 의견 부분 참조.

26) 이러한 비례의 원칙에 대해 자세한 것은 권영성, 헌법학원론 개정판, 법문사, 2009, 352-354쪽; 김철수, 헌법학신론 제21전정신판, 박영사, 2013, 437-442쪽; 성낙인, 헌법학 제19판, 법문사, 2019, 962-970쪽; 양삼승, "과잉금지의 원칙-특히 독일에서의 이론과 판례를 중심으로-", 헌법논총 제1집, 헌법재판소, 1990, 111-142쪽; 이희훈, 기본권론 초판, 박영사, 2021, 42-66쪽; 이희훈, "일반 교통방해죄와 외교기관 인근 집회 시위 금지에 대한 헌법적 평가", 공법연구 제39집 제3호, 한국공법학회, 2011, 284-285쪽; 장영수, 헌법학 제9판, 홍문사, 2015, 196쪽; 전광석, 한국헌법론 제13판, 집현재, 2018, 268-271쪽; 정종섭, 헌법학원론 제10판, 박영사, 2015, 379-384쪽; 한수웅, 헌법학 초판, 법문사, 2011, 456-470쪽; 허영, 한국헌법론 전정 11판, 박영사, 2015, 297-299쪽.

27) 이하의 첫째부터 넷째까지의 내용들은 김상겸, "생명권과 사형제도: 사형제도 존치론을 중심으로", 헌법학연구 제10권 제2호, 한국헌법학회, 2004, 247-248쪽; 헌법재판소 2010. 2. 25. 선고 2008헌가23 결정에서 헌법재판소 재판관 5인의 합헌 의견 부분 참조.

28) 헌법재판소 1996. 11. 28. 선고 95헌바1 결정.

www.kci.go.kr

범죄인 자신에 의한 재범의 가능성을 영구히 차단함으로써 사회를 방어한다는 공익상의 목적을 가진 형벌이므로, 이러한 사형제의 입법의 목적은 정당하다고 할 것이다.

둘째, 사형은 인간의 죽음에 대한 공포의 본능을 이용한 가장 냉엄한 궁극의 형벌로서 이를 통한 일반적 범죄예방의 효과가 있다고 볼 수 있다. 따라서 일반적 범죄예방의 목적을 달성하기 위한 적합한 수단이고, 잔혹한 방법으로 다수의 인명을 살해하는 등의 극악한 범죄의 경우에 그 법익침해의 정도와 범죄자의 책임의 정도는 가늠할 수 없을 만큼 심대하며, 수많은 피해자 가족들의 형언할 수 없는 슬픔과 고통, 분노 및 일반 국민이 느낄 불안과 공포 및 분노까지 고려하면, 이러한 극악한 중범죄에 대해서 우리나라의 헌법 질서가 허용하는 한도 내에서 그 불법의 정도와 책임에 상응하는 강력한 처벌을 하는 것이 정의의 실현을 위하여 필수불가결하다 할 것이므로, 가장 무거운 형벌인 사형은 이러한 정당한 응보를 통한 정의의 실현을 달성하기 위한 적합한 수단이라고 할 것이다.

셋째, 사형이 가석방이 불가능한 종신형보다 일반적 범죄예방의 효과가 크다고 볼 수 있으므로, 사형을 통하여 극악한 범죄의 발생을 보다 더 감소시킬 수 있어, 무고하게 살해되는 국민의 수가 사형제의 영향으로 감소될 수 있으며, 잔혹한 방법으로 다수의 인명을 살해한 범죄 등 극악한 범죄의 경우에는 범죄자에 대한 가석방이 불가능한 종신형의 선고만으로는 형벌로 인한 범죄자의 법익침해의 정도가 당해 범죄로 인한 법익침해의 정도 및 범죄자의 책임에 미치지 못하게 되어 범죄와 형벌 사이의 균형성을 잃게 되어 범죄 피해자들의 가족 및 국민의 정의의 관념에 부합되지 않게 될 것이다. 따라서 사형은 그보다 완화된 형벌인 가석방이 불가능한 종신형에 비하여 일반적 범죄예방의 목적 및 정당한 응보를 통한 정의의 실현이라는 목적을 달성함에 있어서 더 효과적인 수단이라고 할 것이고, 이러한 입법목적의 달성을 함에 있어서 사형과 동일한 효과를 나타내면서도 사형보다 범죄자에 대한 법익침해 정도가 작은 다른 형벌이 명백히 존재한다고 보기 어려우므로, 사형제는 최소 침해의 원칙에 위반된다고 할 수 없다.

넷째, 사형으로 인하여 침해되는 사익은 타인의 생명을 박탈하는 등의 극악한 범죄를 저지른 자의 생명의 박탈이라고 할 것인바, 이는 범죄자의 자기책임에 기초한 형벌의 효과에 기인한 것으로서, 엄격하고 신중한 형사소송절차를 거쳐 생명이 박탈된다는 점에서 극악무도한 범죄행위로 인하여 무고하게 살해당하였거나 살해를 당할 위험성이 있는 국민의 생명권의 박탈 및 그 위험과는 동일한 성격을 가진다고 보기 어렵고, 두 생명권이 서로 충돌하게 될 경우에 범죄행위로 인한 무고한 국민의 생명권의 박탈의

www.kci.go.kr

방지가 보다 우선시되어야 할 가치다. 따라서 사형제에 의해 달성되는 범죄예방을 통한 무고한 국민의 생명의 보호 등 중대한 공익의 보호와 정의의 실현 및 사회방위라는 공익은 사형제로 발생하는 극악한 범죄를 저지른 자의 생명권 박탈이라는 사익보다 결코 작다고 볼 수 없고, 다수의 인명을 잔혹하게 살해하는 등의 극악한 범죄에 대해 한정적으로 부과되는 사형이 그 범죄의 잔혹함에 비하여 과도한 형벌이라고 볼 수 없으므로, 사형제는 법익 균형의 원칙에 위반되지 않는다고 보아, 사형제는 헌법상 비례의 원칙에 위반되지 않아 합헌으로 볼 수 있다.

1.3 사형제는 헌법 제10조의 인간의 존엄과 가치 규정에 위반되지 않는 점

헌법 제10조는 "모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다."라고 규정하여 모든 기본권의 종국적 목적이자 기본이념이라 할 수 있는 인간의 존엄과 가치를 규정하고 있다. 이러한 인간의 존엄과 가치 규정은 국가가 헌법에 규정된 개별적 기본권을 포함하여 헌법에 열거되지 아니한 기본권들도 이를 보장해야 하고, 이를 통하여 개별 국민이 가지는 인간으로서의 존엄과 가치를 존중하고 확보하여야 한다는 헌법의 기본원리를 선언한 것이라고 할 것인바,[29] 우리나라 헌법은 간접적으로나마 사형을 형벌의 한 종류로 인정하고 있고, 사형이 극악한 범죄에 한정적으로 선고되는 한 범죄자의 생명권을 제한함에 있어서 헌법상 비례의 원칙에 위반되지 아니한다고 할 것이므로, 사형제가 범죄자의 생명권 박탈을 내용으로 한다는 이유만으로 곧바로 헌법 제10조의 인간의 존엄과 가치 규정에 위반된다고 볼 수 없다. 그리고 사형은 형벌의 한 종류로서, 다수의 무고한 생명을 박탈하는 살인범죄 등의 극악한 범죄에 예외적으로 부과되는 한, 사형제는 공익의 달성을 위해 무고한 국민의 생명을 그 수단으로 삼는 것이 아니라 형벌의 경고 기능을 무시하고 극악한 범죄를 저지른 자에 대해 그 중한 불법성의 정도와 책임에 상응하는 형벌을 부과하는 것이므로, 이는 당해 범죄자가 스스로 선택한 잔악무도한 범죄행위의 결과에 해당하여 이러한 형벌제도를 두고 범죄자를 오로지 사회방위라는 공익의 추구를 위한 객체로만 취급함으로써 범죄자의 인간으로서의 존엄과 가치를 침해한 것으로 보아 위헌이라고 볼 수 없다.[30]

29) 헌법재판소 2001. 7. 19. 선고 2000헌마546 결정; 헌법재판소 2004. 10. 28. 선고 2002헌마328 결정.
30) 성낙인, 앞의 책, 1010쪽.

www.kci.go.kr

또한 사형을 선고하는 법관이나 이를 집행하는 교도관 등은 인간의 생명을 박탈하는 사형을 선고하거나 집행하는 과정에서 인간으로서의 자책감을 가지게 될 여지가 있어 사형제는 이들의 인간의 존엄과 가치를 위반한다는 주장에 대해서는 사형제가 무고한 국민의 생명 보호 등 극히 중대한 공익을 보호하기 위한 것으로서, 이러한 공익을 보호하여야 할 공적 지위에 있는 법관 및 교도관 등은 다른 형벌의 적용과 집행을 하는 것과 같이 사형의 적용과 집행을 수인할 의무가 있다고 할 것이다. 따라서 법관 및 교도관 등이 인간적 자책감을 가질 수 있다는 이유만으로 사형제가 법관 및 교도관 등을 공익 달성을 위한 도구로서만 취급하여 그들의 인간으로서의 존엄과 가치를 침해하는 위헌적인 형벌제도라고 볼 수 없으므로 사형제는 합헌으로 볼 수 있다.[31]

1.4 사형제는 형벌 중 가장 큰 일반적 범죄예방의 효과를 가지고 있는 점

사형은 인간의 죽음에 대한 공포본능을 이용한 가장 냉엄한 궁극의 형벌로서 그 위하력이 강한 만큼 이를 통한 일반적 범죄예방의 효과도 더 클 것으로 추정되고, 국민의 법 감정에 비추어 볼 때 결코 극악한 중범죄자에 대한 사형제가 부당하다고 할 수 없으며, 사형의 범죄억제의 효과가 무기징역형의 범죄억제력보다 명백하고 현저히 높다고 하는 것에 대한 합리적이고 실증적인 근거가 미약한 것과 같이 무기징역형이 사형과 대등한 또는 오히려 더 높은 범죄억제의 효과를 가져와 무기징역형만으로도 사형의 일반적 범죄예방의 효과를 대체할 수 있다는 위헌론의 주장도 그 실증의 미약성으로 인하여 가설의 수준을 넘지 못한다고 할 것이기 때문에 사형제는 합헌으로 볼 수 있다.[32]

즉, 사형은 가석방이 불가능한 종신형보다도 범죄자에 대한 법익 침해의 정도가 훨씬 크고, 인간의 생존 본능과 죽음에 대한 근원적인 공포감을 고려할 때, 사형은 잠재적 범죄자를 포함하는 모든 국민에 대하여 가석방이 불가능한 종신형보다 더 큰 위하력을 발휘하여 가장 강력한 범죄억지력을 가지고 있다고 할 것인바, 이에 입법자가 사형이 가석방이 불가능한 종신형보다 더 큰 일반적 범죄예방의 효과를 가지고 있다고 보아 형벌의 한 종류로 형법 등에 규정해 놓은 이상, 이러한 입법자의 판단은 존중되어야 하고, 가석방이 불가능한 종신형이 사형과 동일한 또는 오히려 더 큰 일반적 범죄예방효

31) 김상겸, 앞의 논문, 250-251쪽; 헌법재판소 2010. 2. 25. 선고 2008헌가23 결정에서 헌법재판소 재판관 5인의 합헌 의견 부분 참조.

32) 김상겸, 위의 논문, 254쪽; 헌법재판소 1996. 11. 28. 선고 95헌바1 결정에서 헌법재판소 재판관 7인의 합헌 의견 부분 참조.

www.kci.go.kr

과를 가지므로, 가석방이 불가능한 종신형으로 사형을 대체할 수 있다는 사형제에 대한 위헌론의 주장은 이를 인정할 만한 명백한 근거가 없는 이상 이를 받아들일 수 없어 사형제는 합헌이라고 할 것이다.[33]

또한 인간의 생명권도 헌법상 기본권 중의 하나인바, 생명권을 모든 규범체계와 무관하다거나 타인의 기본권을 초월하여 무제한으로 타당한 절대적인 권리라고 할 수 없으므로, 현실적으로 사형제가 잔인하고 반인륜적인 흉악범죄 등으로부터 사회를 방어하고 공공의 이익을 보호하기 위한 최소한의 안전판으로서 일반적 범죄예방의 효과를 기하고 있다고 할 것이므로, 현행 헌법질서 내에서의 사형제 자체의 존재 이유 및 필요성은 최소한 그 범위 내에서 인정될 수 있다.[34]

1.5 오판의 가능성은 사법체계상 부득이하며, 철저한 증거조사 등에 의한 최소화를 통하여 해소할 수 있는 점

인간은 완벽한 존재일 수가 없고 그러한 인간이 만들어낸 어떠한 사법제도 역시 결점이 없을 수는 없다는 점에 비추어 볼 때, 형사재판에 있어서 사형에 대한 오판의 가능성은 사법제도가 가지는 숙명적인 한계라고 볼 것이지 사형이라는 형벌제도 자체의 문제라고 보기 어려우므로, 오판의 가능성 및 그 회복의 문제는 피고인의 방어권을 최대한 보장하고, 철저한 증거조사 절차를 거쳐서 사형에 대한 유죄를 인정토록 하는 형사공판절차제도의 개선과 오판을 한 하급심 판결이나 확정된 판결을 시정할 수 있는 심급제도의 개선 및 재심제도 등의 제도적 장치와 그에 대한 개선을 통하여 오판의 가능성을 최소화하여 해소할 문제이므로 사형제는 합헌이라고 볼 수 있다.[35]

2. 사형제에 대한 위헌론의 사유나 근거

사형제에 대하여 위헌으로 보는 견해는 대체로 크게 다음과 같이 다섯 가지의 사유나 근거들을 제시하고 있다.

---

33) 헌법재판소 2010. 2. 25. 2008헌가23 결정에서 헌법재판소 재판관 5인의 합헌 의견.

34) 헌법재판소 2010. 2. 25. 2008헌가23 결정에서 민형기 헌법재판소 재판관의 의견.

35) 김상겸, 앞의 논문, 255쪽; 헌법재판소 2010. 2. 25. 선고 2008헌가23 결정에서 헌법재판소 재판관 5인의 합헌 의견 부분 참조.

www.kci.go.kr

2.1 헌법상 사형제를 인정하는 규정이 없는 점

먼저 1962년 제5차 개정 헌법에서 도입된 헌법 제110조 제4항 본문은 전시나 사변 또는 이에 준하는 국가비상사태를 전제로 하는 비상계엄 하의 군사재판이라는 긴급하고 특수한 상황에서 군인・군무원의 범죄나 군사에 관한 간첩죄의 경우, 초병・초소・유독음식물공급・포로에 관한 죄 중 법률이 정한 경우 등 특정한 종류의 범죄에 대한 신속한 처단을 위하여 마련된 것이다.[36]

그리고 1987년의 제9차 개정 헌법에서 도입된 헌법 제110조 제4항 단서는 비록 전시나 사변 등 긴박하고 예외적인 상황이라 할지라도 사형에 따른 인권침해의 심각성과 사형의 회복불가능성을 고려하여 적어도 사형선고 만큼은 사법절차를 통한 불복이 가능하도록 해 주기 위하여 헌법 제110조 제4항 단서에서 "다만 사형을 선고한 경우에는 그러하지 아니하다."라는 규정을 새로 도입한 것으로 보는 것이 타당하다. 이러한 헌법 제110조 제4항 단서의 도입 배경이나 그 문언상의 맥락에 비추어 볼 때, 법률상 존재하는 사형의 선고를 억제하여 최소한의 인권을 존중하기 위해서 규정된 것이라고 할 것이므로, 동 규정을 사형제를 헌법에서 인정하는 것으로 해석하는 것은 타당하지 않다. 즉, 인간으로서의 존엄과 가치를 규정하고 있는 헌법 제10조는 우리나라 헌법상 근본적 규범으로 작용하는바, 사형제에 대한 합헌론의 주장처럼 헌법 제110조 제4항 단서를 간접적으로 사형제에 대하여 인정하는 근거라는 적극적인 의미를 부여한다면 이와 반대로 인간의 존엄과 가치를 규정한 근본적인 규정인 헌법 제10조의 의의를 축소해 버리는 부당한 결과를 초래하며, 헌법 제110조 제4항 단서는 어떠한 경우에도 사형선고에 대한 불복절차를 인정하여 법률상 존재하는 사형의 선고를 억제하기 위한 것으로, 오히려 사형제의 심각성 내지 문제점을 부각시킨 규정이라고 볼 것이다. 따라서 헌법 제110조 제4항 단서가 간접적으로 헌법상 사형제를 인정하는 근거 규정이라고 보기 어려우므로, 사형제는 위헌이라고 할 것이다.[37]

2.2 사형제는 헌법상 비례의 원칙에 위반되는 점

첫째, 사형은 범죄자의 생명을 박탈하는 것이므로 범죄자에 대한 개선의 가능성을

36) 헌법재판소 2010. 2. 25. 선고 2008헌가23 결정에서 김희옥 헌법재판소 재판관의 의견 부분 참조.

37) 전광석, 앞의 책, 282쪽; 헌법재판소 2010. 2. 25. 선고 2008헌가23 결정에서 김희옥/목영준 헌법재판소 재판관들의 의견 부분 참조.

www.kci.go.kr

포기하는 형벌인바, 형벌의 목적의 하나인 개선의 목적에 반하여 사형제의 정당성을 인정할 수 없다. 그리고 개선이 절대적으로 불가능한 범죄인이 있을 수 있는지의 문제는 인간의 판단만으로 결정하기에 불가능한 문제라고 할 것인바, 국가는 모든 범죄인에 대한 개선의 가능성을 긍정적으로 받아들여야 할 것이고, 범죄의 책임이 범죄인 개인에게만 있는 것이 아니라, 그가 속해 있는 사회에도 있는 것으로 보아야 할 것인바, 범죄인에 대한 교화 및 개선이라는 형벌의 특별 예방의 목적을 결코 포기할 수 없는 것이다. 만약 사형제를 존치시킨다면 형벌의 특별 예방의 목적 달성을 포기하는 것이므로, 사형제의 입법 목적의 정당성을 인정할 수 없다.

둘째, 사형이 인간의 죽음에 대한 공포본능을 이용한 가장 냉엄한 형벌로서 그 위하력을 통한 일반적 범죄예방의 효과를 가지느냐의 문제에 대하여 많은 국내외의 실증적 연구조사의 결과에 의하면, 사형에 의한 일반적 범죄예방의 효과를 인정하는 견해는 소수에 불과하고 오히려 다수의 견해는 사형에 의한 일반적 범죄예방의 효과를 인정하지 않고 있다. 이렇듯 사형은 형벌의 목적의 하나인 범죄의 일반적 범죄예방의 실효를 거두고 있다고 할 수 없고, 그 효과도 무기징역형을 최고의 형벌로 정하는 경우와 비교해 볼 때 큰 차이가 있다고 할 수 없다. 따라서 사형제도는 형벌의 한 수단으로서 적정하다고 볼 수 없다.

셋째, 사형은 영구히 사회로부터 범죄자를 격리한다는 점에 있어서, 사형과 가석방 없는 무기징역형 간에 별다른 차이를 찾아볼 수 없으므로, 반드시 사형제에 의하지 않더라도 가석방 없는 무기징역형 제도, 즉 종신형 제도를 통하여 형벌의 일반적 범죄예방의 목적이나 효과를 충분히 달성할 수 있다고 할 것이다. 따라서 극악한 중범죄자의 재범을 막기 위하여 사형이 꼭 필요하다고 볼 수 없고, 사형을 통하여 달성하려는 사회방위의 목적을 충분히 이룰 수 있는 다른 완화된 수단이 존재함에도 불구하고 굳이 사형을 통하여 범인의 생명을 박탈하는 것은 사회방위의 목적 달성을 위하여 필요한 정도를 넘어 극악한 범죄인의 자유와 권리를 지나치게 과도히 제한하는 것이라는 점에서 최소침해의 원칙에 반한다고 할 것이다.

넷째, 사형은 이로 인하여 사회방위나 사회 보호 등의 국가안전보장이나 질서유지라는 보호하려는 공익보다 극악한 중범죄인의 생명권의 박탈이라는 사익의 피해가 좀 더 크다고 할 것이므로, 법익 균형의 원칙에도 반한다고 보아 사형제는 위헌이라고 할 것이다.[38)]

38) 이러한 첫째부터 넷째까지의 내용에 대해서는 전광석, 위의 책, 281-282쪽; 헌법재판소 1996. 11. 28. 선고,

www.kci.go.kr

2.3 사형제는 헌법 제10조의 인간의 존엄과 가치 규정에 위반되는 점

인간의 생명은 한번 잃으면 다시 절대로 찾을 수 없는 절대적인 가치이며, 인간의 생명은 인간의 존엄과 가치의 근본 가치에 해당하는 것으로, 헌법 제10조에 의하여 제한되면 안되는 헌법의 최고의 가치인바, 헌법 제10조에 규정된 인간의 존엄성에 대한 존중과 보호의 요청은 형사법 등의 적용과 집행의 모든 영역에서 지도적인 원리로 작용한다. 따라서 형사법 등의 영역에서 입법자가 인간의 존엄성을 유린하는 악법의 제정을 통하여 국민의 생명과 자유를 박탈 내지 제한하거나 잔인하고 비인간적인 형벌제도를 채택하는 것은 헌법 제10조에 위반된다고 할 것이다. 즉, 극악한 중범죄를 저지른 인간임을 스스로 포기한 범죄인이라도 여전히 헌법 제10조의 인간으로서의 존엄과 가치를 가지고 있는 인간이라는 존재에 해당하는바, 극악한 중범죄의 일반적 범죄예방의 효과라는 목적을 달성하기 위해서 비인간적인 형벌로서의 사형은 다른 자유형과는 달리 사형선고를 받은 자에게 교화를 통하여 개과천선을 할 수 있는 도덕적인 자유조차 남겨주지 아니하는 형벌제도로서, 한 개인을 전적으로 국가나 사회 전체의 이익을 위한 단순한 수단이나 대상으로 보아, 사형수의 인간의 존엄과 가치를 침해하는 것으로 할 것이다. 또한 사형제는 양심에 반하여 관련 법 규정에 의하여 사형을 언도해야 하는 법관 및 자신의 양심에 반하여 직무상 불가피하게 사형을 집행하는 교도관 등의 양심의 자유와 인간으로서의 존엄과 가치를 침해하는 비인간적인 형벌제도라는 점에서 사형은 인간의 존엄과 가치 등에 위반하여 위헌이라고 할 것이다.[39]

2.4 사형제는 형벌의 일반예방과 특별예방의 효과가 없는 점

사형의 범죄에 대한 일반적 범죄예방의 효과는 하나의 추상적인 학문적 가설일 뿐이지, 이를 과학적으로 명백하게 입증된 적이 없고, 형벌의 본질이 범죄자에 대한 응보에서 범죄자의 교화 및 개선의 교육으로 옮겨가고 있는 추세임을 감안할 때, 국가가 사형을 인정한다는 것은 결국 국가 스스로 범죄인의 사회복귀를 위한 교화와 개선의 노력을 해야 하는 것을 스스로 포기하는 것으로서, 국가가 살인행위를 비난하면서도 스스로

95헌바1 결정에서 조승형 헌법재판소 재판관의 의견 부분과 헌법재판소 2010. 2. 25. 선고 2008헌가23 결정에서 김종대/조대현/목영준 헌법재판소 재판관들의 의견 부분 참조.

39) 김철수, 헌법학개론 제19전정신판, 박영사, 2007, 516쪽; 헌법재판소 1996. 11. 28. 선고 95헌바1 결정에서 김진우 헌법재판소 재판관의 의견 부분 참조.

www.kci.go.kr

사람의 생명을 박탈하는 것에 대하여 이를 정당화시키는 모순에 빠지게 되는 문제가 발생한다. 즉, 극악한 중범죄자를 사형시킴으로써 다른 사람의 중범죄도 일반적으로 예방할 수 있다는 주장에 대해서는 아직껏 실증된 연구결과는 없다는 점에서 사형제는 위헌으로 볼 수 있다.[40)]

2.5 사형제는 오판의 가능성이 있다는 점

법원에서의 재판도 판사라는 사람에 의해서 행하여지는 하나의 제도이기 때문에 오판의 가능성을 절대적으로 배제할 수는 없는바, 이러한 오판이 시정되기 이전에 사형이 집행되었을 경우에는 비록 사형이 집행된 후에 해당 사형수에 대하여 오판임이 판명되더라도 인간의 생명을 결코 다시 원상으로 되돌릴 수는 없다는 점에서 억울하게 사형을 당한 해당 사형수의 생명권은 영원히 구제할 수 없는 문제점을 초래한다는 점에서 사형제는 위헌이라고 할 것이다.[41)]

3. 검토

3.1 헌법 제110조 제4항 단서는 사형제를 인정하는 규정으로 볼 수 없는 점

헌법 제12조 제1항에서 모든 국민은 형법 제41조 제1호 등의 법률에 의하여 사형 등의 처벌을 부과할 수 있도록 규정하고 있어서, 해당 범죄에 대하여 사형 등의 형벌을 부과할 수 있다. 이에 따라 헌법 제110조 제4항 단서에서는 비상계엄이라는 국가의 비상상황 하의 군사재판에서 군인・군무원의 범죄나 군사에 관한 간첩죄의 경우 및 초병・초소・유독음식물공급・포로에 관한 죄 중에서 사형을 선고하는 경우에는 해당 범죄인의 생명권을 최대한 존중 및 보호해 주기 위해서 최종심인 대법원에 사법적 불복절차를 허용해 주어, 형법 등 여러 법률들에서 존재하는 사형제의 남용을 최대한 방지 및 억제하여 해당 범죄인의 헌법 제10조의 인간의 존엄과 가치를 최대한 보장해 주기 위한 것에 헌법 제110조 제4항 단서 규정의 입법 목적이나 취지가 있다는 점에 비추어 볼 때, 헌법 제110조 제4항 단서 규정을 사형제의 인정 규정으로 원용하려는 견해나 태도는 그 타당

40) 헌법재판소 2010. 2. 25. 선고 2008헌가23 결정에서 조대현 헌법재판소 재판관의 의견 부분 참조.

41) 同旨: 전광석, 앞의 책, 282쪽; 헌법재판소 1996. 11. 28. 선고 95헌바1 결정에서 김진우/조승형 헌법재판소 재 판관들의 의견 부분 참조.

www.kci.go.kr

성이 낮은 것으로 판단된다. 즉, 만약 우리나라에서 의안번호 2112795번의 이상민 국회의원이 대표로 발의한 '사형 폐지에 관한 특별법안'이 전격 시행하게 되어, 형법 제41조 제1호 등의 여러 법률 조항들에서 사형이라는 형벌이 폐지가 된 후에, 가석방이 일체 불가능한 무기징역형인 '절대적 종신형'제도로 대체가 될 경우에는 헌법 제110조 제4항 단서는 그 의미를 자동적으로 잃어버리게 되는 것이므로, 향후 헌법 개정을 통하여 명시적으로 헌법 제110조 제4항 단서를 삭제해야 되거나 그 의미를 잃어버리게 될 것이다. 따라서 헌법 제110조 제4항 단서 규정을 사형제의 인정 규정으로 보는 것은 그 타당성이 희박한 것으로 판단된다.

3.2 사형제는 비례의 원칙에 위반된다는 점

3.2.1 사형제는 비례의 원칙 중 수단의 적합성에 위반된다는 점

먼저 사형의 범죄에 대한 일반 예방효과에 대해서는 이를 설득력 있게 뒷받침해 줄 충분한 실증적인 통계자료들이 존재하지 않는 것으로 볼 수 있다. 예를 들어, UN에서는 1988년과 2002년도에 각각 사형의 일반 예방효과에 대한 광범위한 조사의 결과에 의하면 사형제가 살인 억제력을 가진다는 가설을 수용하는 것은 신중하지 못하며, 조사의 결과 통계수치는 사형제를 폐지하더라도 해당 사회에 급작스럽고 심각한 변화가 일어나지는 않는 것을 알 수 있다. 그리고 사형제에 대하여 존치하고 있는 주(州)들과 폐지한 주(州)들이 함께 공존하고 있는 미국의 경우에는 인구 10만명당 살인율이 사형을 폐지한 주에서 오히려 더 낮게 나타나는 것으로 조사되었다. 그리고 1975년에 사형을 폐지한 캐나다의 경우에는 사형을 폐지하기 이전인 1975년 당시 인구 10만명당 살인율이 3.09%에서 사형을 폐지한 이후인 2003년에는 1.73%로, 인구 10만명당 살인율이 사형제의 폐지 전후에 약 44%가 감소된 것으로 나타난 통계자료가 있다.[42] 또한 우리나라에서 1997년 12월 30일에 살인사건이 789건이나 발생하자 흉악범 23명에 대하여 사형을 집행했지만 오히려 1998년에는 살인사건이 966건이나 발생하여 177건의 살인범죄가 증가하였는바, 2000년까지 살인범죄는 약 960-980건의 수준을 유지하다가 2001년에 다시 살인범죄는 1,064건으로 증가된 후, 2006년까지 연 1,000건 이상 살인범죄가 계속해서 발생한 통계자료도 있다.[43] 이러한 여러 통계자료들에 의하면 사회에서 살인사건의 발생율과 사형제의 연

42) 의안번호 2112795번의 이상민 국회의원이 대표로 발의한 '사형 폐지에 관한 특별법안'의 제안 이유 부분 참조.

www.kci.go.kr

관관계는 거의 없다고 볼 것이므로, 사형제는 형벌의 목적인 일반예방효과가 거의 없거나 미비하다고 볼 수가 있다.

그러나 이와 반대로 미국의 텍사스 주(州)에서 사형을 집행하지 않았던 1981년에는 701건의 살인사건이 발생하여 미국 내에서 살인범죄율이 가장 높았으므로, 이에 1982년에 미국의 텍사스 주에서는 사형집행을 부활시켰는바, 1996년에 미국의 텍사스 주의 살인사건이 261건으로 63%나 감소하였던 통계자료와 영국에서 1966년에 사형을 폐지하였는데 사형이 폐지된 전후에 각 20년간의 살인사건 발생률을 비교 분석한 결과 사형을 폐지한 후에 약 60%가 살인범죄율이 증가하였던 통계자료 등도 있다.[44] 이러한 통계자료들에 의하면 사회에서 살인사건의 발생율과 사형제의 연관관계는 유의미하게 있는 것이므로, 사형제는 형벌의 목적인 일반예방효과가 크거나 있는 것으로 볼 수도 있다.

한편 최근 미국에서 사형 집행과 살인 범죄의 위하력에 대한 여러 통계 결과들에 비추어 볼 때, 미국에서 사형 집행과 살인 범죄의 위하력에 의한 사형제의 일반예방효과에 대해서는 해당 조사에서 사용된 여러 다양한 통계적 분석 방법에 따라서, 사형 집행과 살인 범죄의 위하력이 상관관계가 유의미하게 있는 것으로 나타나기도 하고, 이와 반대로 사형 집행과 살인 범죄의 위하력이 전혀 상관관계가 없는 것으로 나타나기도 하며 또는 사형 집행과 살인 범죄의 위하력이 상관관계가 있기는 하지만 그 수치가 매우 미비하게 있는 것으로 나타나기도 하기 때문에, 최근 미국에서 사형 집행과 살인 범죄의 위하력에 의한 사형제의 일반예방효과의 여러 통계 결과나 그 결과 값은 해당 통계적 분석 방법에 따라서 다르게 나타난다는 점에서, 사형제와 일반예방효과에 대한 상관관계나 연계성을 찾는 것 자체에 대하여 회의적이거나 문제점을 제시하는 견해도 있다.[45]

따라서 사형제가 범죄에 대한 일반예방효과가 확실하고 명백하게 있는 것인지 아니면 확실하고 명백하게 없는 것인지 또는 설사 있더라도 그 효과는 매우 미비하게 나타나는 것인지 등에 대해서는 그 어느 쪽도 확실하고 명백하게 옳다고 볼 수가 없는 상황이므로, 이러한 사형제가 범죄에 대한 일반예방효과의 유무에 따라서 사형제의 합헌성이나 위헌성을 주장하는 것은 판단 자체가 불가능하거나 무의미한 것으로 보는 것이 타당한 것으

43) 강은영/박형민, 살인범죄의 실태와 유형별 특성: 연쇄살인, 존속살인 및 여성살인 범죄자를 중심으로, 연구총서 08-11호, 한국형사정책연구원, 2008, 103쪽.

44) 중앙일보, “문재인, 사형제 흉악범죄 억제 효과 없다는 사실 실증됐다...사실은”, <https://www.joongang.co.kr/article/21522010#home>, 검색일: 2022.3.10.

45) 홍문기, “사형제도의 위하력 효과에 대한 연구의 최근 동향: 미국에서 발표된 선행연구를 중심으로”, 형사정책연구 제28권 제1호, 한국형사정책연구원, 2017, 209-210쪽.

www.kci.go.kr

로 판단된다.

이에 비추어 볼 때, 사형제는 극악한 중범죄에 대한 일반예방효과의 기능을 행하는데 확실하고 명백히 기여하고 있다고 보기 어렵다는 점과 범죄는 사회적・경제적・문화적인 상황 전반의 여러 다양한 요인들에 의하여 복합적이고 중층적으로 영향을 받는 것이라고 할 것이므로, 사형제가 일반 예방효과가 있다는 인과관계를 입증하는 것 자체가 무의하거나 매우 어렵다는 점[46]에 비추어볼 때 사형제는 비례의 원칙 중 수단의 적합성에 저촉된다고 보는 것이 타당하다.

또한 형벌은 범죄에 대한 국가와 사회적인 응보 기능과 일반 국민들에 대하여 형벌의 위하력을 통하여 잠재적인 범죄를 억제 내지 방지해 주는 형벌의 일반예방효과의 기능이 있어야 하며, 해당 범죄인에 대한 신체의 자유 등의 일정한 기본권의 제한을 통해서 그 범죄인의 교화 및 개선을 도모하는 이른바 형벌의 특별예방효과의 기능이 있어야 한다. 그런데 형벌 중 사형이라는 제일 중한 생명형은 이 중에서 극악한 중범죄인의 생명을 아예 박탈해 버리는 형벌이므로, 해당 범죄인의 교화 및 개선의 기능 자체가 없기 때문에, 형벌의 목적 중 특별예방효과의 기능을 행할 수 없는 문제점이 있다. 따라서 사형은 형벌의 목적에 적합한 수단이 아니라고 보는 것이 타당하다.[47]

3.2.2 사형제는 비례의 원칙 중 최소 침해의 원칙에 위반된다는 점

만약 사형제에 의하여 형벌의 일반적 범죄예방효과가 있다고 인정하더라도, 사형에 의하여 굳이 해당 극악한 중범죄인의 생명을 박탈하지 않더라도 가석방이 불가능한 무기징역형인 종신형을 통해서 사회방위 효과인 형벌의 일반적 범죄예방효과는 대체하거나 달성할 수가 있을 것이며, 아무리 신중하고 적법한 사법절차를 거치고 훌륭한 법관이 판결을 하더라도 인간이 행하는 재판인 이상 오판의 가능성은 언제나 항상 존재하는 것이므로, 생명을 박탈하는 형벌인 사형은 이러한 오판의 결과, 즉 해당 극악한 중범죄인의 사망에 대하여 이로 인한 범죄인의 회복을 위한 그 어떠한 수단도 행할 수 없고, 그 침해의 정도가 수범자의 입장에서 생명권을 빼앗기는 것이기 때문에 해당 수범자의 피해는 절대로 회복시키거나 되돌릴 수가 없는 지나치게 큰 것이므로, 비례의 원칙 중 최소 침해의 원칙에 반한다고 할 것이다.[48] 즉, 극악한 중범죄자를 사회에서 영원히

46) 헌법재판소 2010. 2. 25. 선고 2008헌가23 결정에서 김종대 헌법재판소 재판관의 의견 부분 참조.
47) 同旨: 전광석, 앞의 책, 281-282쪽.
48) 헌법재판소 2010. 2. 25. 선고 2008헌가23 결정에서 김희옥 헌법재판소 재판관의 의견 부분 참조.

www.kci.go.kr

격리시켜서 사회방위 효과 및 형벌의 일반적 예방효과는 해당 범죄인의 생명을 박탈하지 않더라도 이른바 종신형 제도를 통해서도 달성할 수 있을 것이므로, 사형은 비례의 원칙 중에서 최소 침해의 원칙에위반된다고 보는 것이 타당하다.[49)]

3.2.3 사형제는 비례의 원칙 중 법익 균형의 원칙에 위반된다는 점

바로 위에서 살펴본 것처럼, 사형을 통하여 침해되는 극악한 중범죄자의 생명의 박탈이라는 사익은 수범자에게는 절대적이고 근원적인 기본권인 생명권의 상실을 뜻하는 반면에 이를 통하여 달성하고자 하는 공익은 타인의 생명이나 이에 준하는 매우 중대한 법익을 침해하는 범죄에 대한 사회방위와 그러한 범죄의 예방인바, 사형을 통하여 보호하려는 타인의 생명권이나 이에 준하는 중대한 법익은 이미 그 침해가 종료됨으로써 범죄인의 생명이나 신체를 박탈해야만 하는 긴급성이나 불가피성이 없는 상태이고, 사형제가 추구하는 사회방위와 범죄의 일반예방효과라는 공익이 어느 정도 실효성을 지닌 것인지는 불명확하므로, 사형으로 얻어지는 국가안전보장이나 질서유지 등의 공익의 크기나 비중에 비하여 사형으로 인하여 침해되는 해당 수범자의 생명권이라는 사익 침해의 크기나 비중이 좀 더 크다고 할 것이므로, 비례의 원칙 중 법익 균형의 원칙에 위반한다고 보는 것이 타당하다.[50)]

3.3 사형제는 인간의 존엄과 가치에 위반되는 점

우리나라 헌법 제10조에서 인간의 존엄과 가치를 가지는 인간은 '모든 국민'을 뜻하는 바, 비록 타인의 생명을 해치는 극악한 범죄를 저지른 범죄인이더라도 그는 헌법 제10조의 인간으로서의 존엄과 가치를 가지는 존재에 속하므로, 그를 재범의 가능성을 원천적으로 차단시켜서 사회 전체의 이익이나 다른 범죄의 예방을 위한 수단 또는 복수의 대상인 사회적 장애물로 취급하여 사형을 통하여 극악한 중범죄인에게 인간으로서 자신의 책임 하에 반성과 개선을 할 최소한의 도덕적인 자유조차 남겨주지 않는 것은 우리 헌법 제10조의 인간의 존엄과 가치에 위반된다고 보는 것이 타당하다.[51)] 그리고 여기서 한 걸음 더 나아가 사형의 대체 수단으로 주장되는 가석방이 불가능한 무기징역형인

49) 전광석, 앞의 책, 282쪽.

50) 헌법재판소 2010. 2. 25. 선고 2008헌가23 결정에서 김희옥 헌법재판소 재판관의 의견 부분 참조.

51) 헌법재판소 2010. 2. 25. 선고 2008헌가23 결정에서 김희옥 헌법재판소 재판관의 의견 부분 참조.

www.kci.go.kr

종신형 제도 또한 해당 극악한 중범죄인에 대하여 자유를 다시 회복할 가능성을 아예 봉쇄하거나 차단시켜서 사형제와 마찬가지로 해당 범죄인을 교도소에서 격리된 상태로 교화 및 개선을 시켜서 재사회화하는 것은 불가능하기 때문에 형벌의 특별예방효과의 기능을 행할 수 없다는 점에서,[52] 사형대신에 가석방이 없는 절대적 무기징역형인 종신형을 당연히 적합한 대체 수단으로 보는 것에는 다소 무리가 있거나 문제점이 여전히 존재한다.

이러한 사유로 독일 연방헌법재판소에서는 독일이 1949년에 입법적으로 사형제를 폐지하기 전에 "인간의 존엄성을 침해하는 것은 평생 종신형을 선고받은 중범죄인이 자유를 회복할 수 있는 기회를 주지 않는 것에 있다. 법치주의 원리는 종신형을 선고받은 해당 중범죄인에게 해당 종신형의 집행이 경우에 따라 중단될 수 있는 조건과 이를 적용할 수 있는 절차 규정을 마련한 법을 통해서 실현될 수 있다."라고 판시하여,[53] 종신형을 선고받은 해당 중범죄인의 자유권의 회복 가능성이 일체 없는 사형 대신에 가석방이 없는 절대적 무기징역형인 종신형을 적합한 대체 수단으로 보는 것은 인간의 존엄성에 위반되고 법치주의의 원리에도 위반되는 문제점이 있다고 보았다. 이에 따라 향후 우리나라에서 사형제에 대하여 폐지한 후에 가석방이 없는 '절대적인 종신형'을 대체 수단으로 채택할 것인지 아니면 해당 중범죄인의 개전의 정에 따른 여러 정황을 참작하여 매우 엄격한 여러 실체적・절차적 조건 하에 그의 자유권을 회복시켜 주는 형태의 가석방이나 사면 등이 가능한 이른바 '상대적인 종신형'을 채택할 것인지에 대해서는 이러한 독일의 연방헌법재판소의 판례를 참고하여 매우 신중하게 사형 대신에 적절한 대체 수단으로 채택하는 것이 바람직하다.

3.4 사형제에 의한 오판의 가능성을 부정 또는 경시할 수 없는 점

극악한 중범죄인에게 사형을 선고하는 법원의 판결은 결국 법관이라는 사람이 행하는 것이므로 전지전능한 절대적인 존재인 신(神)이 아닌 이상, 아무리 철저한 증거조사 절차와 심급제도 등을 발달시키더라도 오판의 가능성을 완전히 배제할 수는 없다. 따라서 만약 이러한 오판으로 인하여 진범이 아닌 무고한 사람을 사형을 통해서 죽이게 되면 그 오판으로 인하여 결코 절대로 다시 되돌릴 수 없는 억울하게 잘못된 죽음에

52) 전광석, 앞의 책, 282쪽.
53) *BVerfGE 45, 187*.

www.kci.go.kr

이르게 한 무고한 사람의 생명권을 회복하거나 보상해 줄 수 없으므로 사형제는 위헌성이 높다고 판단된다.

예를 들어, 우리나라에서 1958년에 진보당의 당수였던 조봉암에 대한 사형 사건과 1970년에 이른바 인혁당 재건위 사건에 대한 피고인들의 사형 사건들이 재심에서 모두 무죄로 선고되었던 사례들[54]과 최근 2021년 5월 22일에 미국 CNN의 보도에 의하면 2017년 4월 20일에 사형이 집행된 레델 리에 대하여 그의 무죄 입증에 영향을 미칠 상당한 증거들이 그의 사형 집행이 된 4년이 지나서 뒤늦게 나온 경우 등을 들 수 있다.[55]

Ⅴ. 맺는 말

위의 Ⅳ-3.1번에서 자세하게 살펴본 헌법 제110조 제4항 단서는 현존하는 사형제를 매우 신중하게 행해야 한다는 사형제의 심각성을 부각시키려는 입법의 목적이나 취지에 비추어 볼 때, 헌법 제110조 제4항 단서를 사형을 인정한 규정으로 원용하는 것은 타당하지 않다는 점과 사형제는 형벌의 일반 예방효과를 입증하거나 실증할 수 없고, 사형 대신에 절대적인 종신형이나 또는 상대적인 종신형이라는 대체 수단을 통해서 형벌의 일반 예방효과와 특별 예방효과를 행할 수 있다는 점에서 사형제는 헌법상 비례의 원칙에 저촉될 가능성이 높다는 점 및 사형제는 해당 범죄인의 재사회화의 기능을 행할 수 없기 때문에 헌법상 인간의 존엄과 가치에 위반될 수 있는 점과 사형제에 의한 오판의 가능성을 전면적으로 일체 부정하거나 경시할 수 없다는 점 및 현재 형법 등 약 20여 개의 법률에서 약 110여 개의 규정들에서 광범위하게 사형을 규정하고 있는 것[56]은 위헌성이 높다고 보는 것이 타당하다.[57]

---

54) 전광석, 앞의 책, 282쪽.

55) 서울신문, “범인은 이미 사형됐는데…4년 후 무죄 증거 나와 美 발칵”, <https://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20210522601005>, 검색일: 2022.3.10.

56) 현행 형법과 기타 형사 특별 법률들에 규정되어 있는 사형대상 범죄의 종류와 해당 법 규정들의 자세한 내용들에 대해서는 강석구/김한균, 사형제도의 합리적 축소정비방안, 연구총서 05-31호, 한국형사정책연구원, 2005, 136-149쪽.

57) 비록 우리나라 헌법재판소는 사형제에 대하여 합헌 의견으로 판시하였지만, 지난 1996년 11월 28일에 95헌바1 결정에서 사형제에 대하여 위헌 의견의 헌법재판소 재판관들이 2명이었다가 2010년 2월 25일의 2008헌가23 결정에서는 사형제에 대한 위헌 의견의 헌법재판소 재판관들이 4명으로 늘어났다. 이러한 점에 비추어 볼 때, 우리나라의 헌법재판소에서는 사형제에 대하여 위헌의 입장으로 점차 그 무게가 실려져 가고 있는 것으로 보인다.

www.kci.go.kr

그러나 위의 Ⅱ-2번에서 살펴본 지난 2003년과 최근 2018년에 각각 사형제의 존폐 여부에 대한 우리나라 국민들의 여론조사의 통계자료의 결과에 비추어볼 때, 우리 사회에서 극악한 살인범죄 등의 중범죄인에 대하여 사형을 선고할 수 없도록 사형을 폐지하려는 입법에 대해서는 아직 일반 국민들의 전체적인 합의나 동의가 이루어졌다고 볼 수 없거나 또는 아직까지 사형제의 입법적인 전면 폐지에 대한 국민적 공감대나 여론이 충분히 형성되어 있지 않은 상태인 것으로 평가된다. 따라서 이러한 우리나라의 최근 약 15년 넘게 사형제에 대하여 입법적으로 폐지하려는 것에 대한 부정적인 국민들의 시각이나 의견이 약 66%-80%로 증가해서 나타나고 있는 점에 의할 때, 현재 제21대 국회의 법제사법위원회에 계류되어 있는 의안번호 2112795번으로 '사형 폐지에 관한 특별법안'처럼 전면적이고 급진적으로 입법자가 모든 범죄유형에 대하여 사형제를 해당 법 규정들에서 일제히 모두 폐지한 후에 이른바 '절대적 종신형'제도로 일체 전면적으로 대체하려는 것은 국민주권국가에서 진정한 민주주의의 원리를 보장해 주고 실현하려는 것과 다소 배치될 수 있는 문제점이 있고, 사형제의 유지를 원하는 우리 국민정서와 여론에 악영향을 초래할 수 있다는 점에 비추어 볼 때, 입법자가 사형제를 전면적으로 모두 일제히 관련 법 규정들에서 폐지한 후에 절대적 종신형제로 모두 대체하려는 입법적 시도는 아직은 시기상조인 것으로 판단된다.

따라서 향후 사형제는 다음과 같이 점진적으로 개선하는 것이 바람직하다.

먼저 향후 의회주의 하에 입법을 행하는 국회에서는 점진적으로 현행 사형을 법정형으로 규정하고 있는 형법 등 약 20여 개의 법률에서 약 110여 개의 조문과 약 160여 개의 범죄의 구성요건으로 규정되어 있는 것 중에서 군형법 제42조 제2항의 유해음식물 공급 치상죄, 보건범죄 단속에 관한 특별조치법 제2조 제1항 제3호의 부정식품 제조 등의 치상죄, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제3조 제2항의 특수 강도강간 등의 죄 등과 같이 생명권의 침해가 없는 상해나 강간 등의 신체적 법익 침해에 대한 범죄에 해당하는 경우와 형법 제119조의 폭발물 사용죄, 군형법 제6조의 반란 목적의 군용물 탈취죄, 항공안전 및 보안에 관한 법률 제39조 제1항의 항공기 파손죄 등과 같이 생명이나 신체에 대한 침해가 없고 적전(敵前)에 범한 것이 아니지만, 폭행 등의 적극적 침해행위로 공공의 안전을 해치거나 위태롭게 하는 범죄의 종류에 해당되는 경우 및 군형법 제75조 제1항의 군용물 등 범죄에 대한 형의 가중처벌, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제10조의 통화위조의 가중처벌, 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 제4조 제1항 제1호의 단체 등의 구성·활동죄 등과 같이 생명과 신체에 대한 침해가 없고, 폭행 등의 적극적

www.kci.go.kr

침해행위도 없으며, 공공의 안전 이외의 국가적·사회적 법익을 침해하는 범죄에 해당하는 경우 등일 때에 사형을 선고할 수 있도록 규정하는 것은 원칙적으로 과잉 형벌에 해당할 수 있는 문제점이 발생하므로, 이러한 범죄의 종류나 유형들에 대한 사형제를 두고 있는 부분을 삭제하거나 폐지시켜서 사형이 부과될 수 있는 범죄의 종류들을 극악한 살인 범죄 등에 한하여 행할 수 있도록 축소하는 것이 바람직하다. 그리고 현행 사형이 규정되어 있는 범죄들 중에서 대부분 그 미수범도 함께 처벌하고 있는바, 이는 형사책임주의나 비례의 원칙에 저촉될 문제점이 있다. 따라서 이러한 범죄유형의 미수범들에게 사형을 선고할 수 있는 법 규정들을 점차 폐지시켜 나가는 것이 바람직하다.[58] 이에 대하여 중국은 지난 2011년 5월에 사형이 규정된 범죄의 구성요건들을 총 68개에서 55개로 축소하여 밀수, 절도, 도굴, 영수증 위조 및 판매 등 13개 경제 및 비폭력범죄에 대해서 사형을 제외하도록 하는 중국 형법의 개정과 사형집행유예 제도를 운영하고 있는 점을 참고해 볼 만하다.[59]

그리고 사형제가 우리 법제에서 계속 존치하는 동안에 법원은 피고인에게 사형을 부득이하게 선고할 때에는 해당 범죄인의 범행의 동기, 태양, 범행의 수단, 잔학성, 성장과정, 피해자와의 관계, 범죄사건 결과의 중대성, 피해자의 수, 범죄에 대한 피해회복의 정도, 재범의 우려, 연령, 직업과 경력, 평소의 행동경향, 지능, 범행 후의 정황 등 양형의 여러 조건 사항들을 모두 충분하게 심리한 후에, 해당 중범죄인의 생명을 더 이상 존치시킬 수 없을 만큼 죄책이 심히 중대하고 죄형의 균형이나 해당 중범죄의 일반 예방효과의 견지에 비추어 볼 때 사형이라는 극형이 불가피한 경우에 한정하는 등 피고인에 대한 사형선고의 여부를 매우 엄격한 실체적·절차적인 조건 하에 신중히 결정하도록 사형제에 대한 관련 법 규정들이나 양형지침 등을 개선하는 것이 바람직하다.[60]

또한 사형에 대한 대체 수단의 형벌의 명칭은 '(상대적) 종신형'으로 정하고, 법원이 이러한 (상대적) 종신형을 선고할 때에는 해당 유기징역형의 형기의 상한을 30년 이상 50년 이하의 범위 내에서 가석방 불허기간을 정하고, 이러한 가석방의 관련 심사 절차들도 매우 엄격하고 까다롭게 규정하여 사형제의 대체 수단의 형벌로서의 공정성을 높이기 위해서 무기 수형자와 다르게 종신 수형자의 경우에는 법무부가 아닌 법원에 의하여 가석방의 결정을 할 수 있도록 입법 정책적으로 개선하고, 이러한 종신 수형자의 가석방

58) 한영수/이진국/이덕인/김도우/이자영, 앞의 보고서, 52-53쪽; 헌법재판소 2010. 2. 25. 선고 2008헌가23 결정에서 민형기 헌법재판소 재판관의 의견 부분 참조.

59) 이덕인, "중국 사형제도의 현상과 전망", 형사정책연구 제21권 제2호, 한국형사법무정책연구원, 2010, 357쪽.

60) 대법원 1987. 10. 13. 선고 대판87도1240 판결; 대법원 2000. 7. 6. 선고 2000도1507 판결.

www.kci.go.kr

의 기간은 사망할 때까지의 기간으로 하여 종신형의 의미가 퇴색되지 않도록 하며, 가석방이 된 자는 보호관찰과 전자발찌 등의 전자 감시나 전자 통제 장치를 필수적으로 함께 부과하도록 개선하는 것이 바람직하다.[61]

이와 관련하여 독일은 기본법 제102조에서 "사형은 폐지된다(Die Todesstrafe ist abgeschaft)"라고 명문으로 규정하여, 사형을 독일 기본법에서 명시적으로 폐지하였다. 이렇게 사형제도를 헌법적 차원에서 폐지한 1949년에 독일은 그 당시에 사형의 대체형으로 절대적 종신형 제도를 채택하였다. 그러나 이후 1977년에 독일 연방헌법재판소는 "종신형을 선고받은 자도 근본적으로 자유를 찾을 수 있는 가능성이 있어야 하므로, 종신형의 집행을 중지할 수 있는 전제 조건 하에서 종신형을 법으로 규정하는 것이 법치국가의 임무다."라는 사유로, 가석방이 전혀 불가능한 이른바 절대적 종신형 제도에 대하여 위헌으로 판시하였다.[62]

이러한 독일 연방헌법재판소의 이른바 절대적 종신형 제도에 대한 위헌판결에 의하여 이후 독일은 독일 형법 제57조 a 규정에서 독일 법원이 수형자가 15년 이상을 교도소에서 복역한 수형자에게 수감을 계속해야 할 중대한 책임이 없는 경우 및 수형자에게 잔형이 집행되지 않더라도 장래에 재범할 우려가 없는지를 심사했을 때 이를 인정할 수 있는 경우와 수형자가 동의한 경우라는 요건을 모두 충족한 경우에 한하여, 5년간의 보호관찰을 조건으로 종신형의 가석방제도 즉, 보호관찰부 가석방제도를 허용하는 이른바 '상대적 종신형 제도'로 전격 변경해서 시행하고 있다.

향후 우리나라 국회도 이러한 독일의 사례에 비추어, 해당 사형 폐지 특별법안에서 사형을 폐지하는 대신에 독일처럼 이른바 '상대적 종신형 제도'를 그 대체형벌로 선택하는 개선방향을 적극 검토 및 모색해 볼 필요가 있다. 왜냐하면 향후 사형 폐지 특별법안에서 사형제를 폐지하는 대신에 '절대적 종신형 제도'를 선택한다면 또다시 독일처럼 '상대적 종신형 제도'로의 변경에 대한 위헌적 문제에 대한 사회적 논란이나 분쟁이 또다시 발생할 수 있기 때문이다.

---

61) 한영수/이진국/이덕인/김도우/이자영, 앞의 보고서, 127쪽.

62) *BVerfGE 45, 187.* 이에 대한 것은 이한규, 사형폐지에 관한 특별법안 검토보고서, 국회 법제사법위원회, 2009, 11쪽.

www.kci.go.kr

참고문헌

1. 단행본

권영성, 헌법학원론 개정판, 법문사, 2009.

김철수, 헌법학개론 제19전정신판, 박영사, 2007.

_____, 헌법학신론 제21전정신판, 박영사, 2013.

성낙인, 헌법학 제19판, 법문사, 2019.

이희훈, 기본권론 초판, 박영사, 2021.

장영수, 헌법학 제9판, 홍문사, 2015.

전광석, 한국헌법론 제13판, 집현재, 2018.

정종섭, 헌법학원론 제10판, 박영사, 2015.

한수웅, 헌법학 초판, 법문사, 2011.

허　영, 한국헌법론 전정 11판, 박영사, 2015.

2. 학술지

김상겸, “생명권과 사형제도: 사형제도 존치론을 중심으로”, 헌법학연구 제10권 제2호, 한국헌법학회, 2004, 221-262쪽.

김영옥, “사형제도에 관한 판례연구”, 형사법연구 제8호, 한국형사법학회, 1995, 63-82쪽.

박용철, “미국의 사형제도 개괄”, 비교형사법연구 제12권 제1호, 한국비교형사법학회, 2010, 333-353쪽.

손미숙, “살인을 했다면 그는 죽어야 한다. -칸트와 형법-”, 법철학연구 제14집 제3호, 한국법철학회, 2011, 207-228쪽.

양삼승, “과잉금지의 원칙-특히 독일에서의 이론과 판례를 중심으로-” 헌법논총 제1집, 헌법재판소, 1990, 111-157쪽.

오영근, “미국의 사형제도”, 법학 제54・55호(합본), 서울대 법학연구소, 1983, 291-306쪽.

이덕인, “중국 사형제도의 현상과 전망”, 형사정책연구 제21권 제2호, 한국형사법무정책연구원, 2010, 351-378쪽.

이희훈, “일반 교통방해죄와 외교기관 인근 집회 시위 금지에 대한 헌법적 평가” 공법연구 제39집 제3호, 한국공법학회, 2011, 265-292쪽.

홍문기, “사형제도의 위하력 효과에 대한 연구의 최근 동향: 미국에서 발표된 선행연구를

www.kci.go.kr

중심으로", 형사정책연구 제28권 제1호, 한국형사정책연구원, 2017, 205-235쪽.
Carmen, Rolando V.del, 최석윤 옮김, "사형에 관한 미국 연방대법원의 판례", 형사정책연구 제10권 제1호, 한국형사정책연구원, 1999, 165-184쪽.

3. 기타 자료

강석구/김한균, 사형제도의 합리적 축소정비방안, 연구총서 05-31호, 한국형사정책연구원, 2005.
강은영/박형민, 살인범죄의 실태와 유형별 특성: 연쇄살인, 존속살인 및 여성살인범죄자를 중심으로, 연구총서 08-11호, 한국형사정책연구원, 2008.
의안번호 2112795번, 이상민 국회의원이 대표 발의, 사형 폐지에 관한 특별법안.
한영수/이진국/이덕인/김도우/이자영, 사형제도 폐지 및 대체형벌 실태조사, 2018년인권상황 실태조사 연구용역보고서, 국가인권위원회, 2018.

4. 웹자료

경향닷컴, "사형제도 유지해야, 여론 오히려 늘었다", <https://www.khan.co.kr/national/national-general/article/200912160956191>, 검색일: 2022.3.10.
국제엠네스티, "2020년 전세계 사형 현황을 담은 <연례사형보고서> 발표", <https://amnesty.or.kr/40995/>, 검색일: 2022.3.10.
문화일보, "살인범이 복역 중 또 살인…대선서 사형제 존폐 논쟁 촉발", <http://www.munhwa.com/news/view.html?no=20220206MW075442347046>, 검색일: 2022.3.10.
서울 경제, "사형제 폐지에…이재명 찬성 vs. 윤석열 반대", <https://www.sedaily.com/NewsView/26294ITSBW>, 검색일: 2022.3.10.
서울신문, "범인은 이미 사형됐는데…4년 후 무죄 증거 나와 美 발칵", <https://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20210522601005>, 검색일: 2022. 3.10.
조선일보, "박근혜 사형제도, 흉악범에 경고 효과, 문재인 등 민주당 후보들 사형제 폐지", <http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2012/09/05/2012090500145.html>, 검색일: 2022.3.10.
중앙일보, "문재인, 사형제 흉악범죄 억제 효과 없다는 사실 실증됐다...사실은", <https://www.joongang.co.kr/article/21522010#home>, 검색일: 2022.3.10.

www.kci.go.kr

5. 우리나라 및 외국 판례

대법원 1963. 2. 28. 선고 62도241 판결.
대법원 1987. 9. 8. 선고 87도1458 판결.
대법원 1987. 10. 13. 선고 대판87도1240 판결.
대법원 1990. 4. 24. 선고 90도319 판결.
대법원 1994. 12. 19. 선고 94초123 판결.
대법원 2000. 7. 6. 선고 2000도1507 판결.
헌법재판소 1991. 7. 22. 선고 89헌가106 결정.
헌법재판소 1996. 11. 28. 선고 95헌바1 결정.
헌법재판소 2001. 7. 19. 선고 2000헌마546 결정.
헌법재판소 2004. 10. 28. 선고 2002헌마328 결정.
헌법재판소 2010. 2. 25. 선고 2008헌가23 결정.
Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972).
Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976).
Coker v. Georgia, 433 U.S. 584 (1977).
Enmund v. Florida, 458 U.S. 782 (1982).
Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002).
Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).
BVerfGE 45, 187.
日最判, 昭 23. 3. 12, 刑集 2. 3.
日最判, 昭 24. 8. 18, 刑集 3. 9.

www.kci.go.kr

[Abstract]

Issues and Improvement Direction of the Death Penalty

Lee, Hie-Houn*

The death penalty is highly unconstitutional for the following four main reasons.

First, in modern criminal law, there must be a retribution effect of punishment, a general prevention effect, and a special prevention effect. However, the death penalty is highly unconstitutional because it deprives the life of a vicious felon and has no special preventive effect on punishment, and violates human dignity under the constitution due to permanent deprivation of the right to life of a condemned person.

Second, the proviso to clause 4 of Article 110 of the Korean Constitution is intended to emphasize the seriousness of the death penalty, and it is unlikely to see this legal regulation as a regulation that recognizes the death penalty.

Third, the general preventive effect of punishment by the death penalty cannot be demonstrated, and instead of the death penalty, the general preventive effect or special preventive effect of punishment can be performed through an alternative means of absolute life imprisonment or relative life imprisonment. Therefore, the death penalty is highly unconstitutional because it violates the principle of balancing test under the constitution.

Fourth, the death penalty is highly unconstitutional because there is a possibility of misjudgment.

However, the results of the National Human Rights Commission of Korea's 2003 and 2018 survey on whether or not the death penalty should be maintained by about 66 percent and 80 percent, respectively. Therefore, in order to guarantee and realize the principle of democracy in a national sovereign state, a radical improvement direction is not desirable to abolish the death penalty altogether and replace it with an "absolute life imprisonment" system. Therefore, it is desirable for the National Assembly to gradually reduce the types of crimes subject to death, such as limiting the types of crimes that can be imposed on the death penalty

* Full Professor of Law and Police at SunMoon University

www.kci.go.kr

to an appropriate extent.

And the National Assembly, after improving the death penalty first, will abolish the death penalty if more than half of the Korean people agree to abolish the death penalty in the future, and instead, it will be able to parole by various stringent and demanding substantive and procedural requirements in the case of at least 30 years to up to 50 years in prison and high possibility of improvement, rather than the 'absolute life sentence' system, which does not have a special preventive effect of punishment. It is desirable to improve the system of a large life sentence.

Also, if a felon who has been sentenced to a relative life sentence like Germany is paroled, it is desirable to improve by the court's judgment, not the Ministry of Justice, to the form of mandatory imposition of electronic monitoring or electronic control devices such as probation and electronic bracelets for a considerable period of up to five years, for example.

[Key Words] Death Penalty, Retribution Effect, General Preventive Effect, Special Preventive Effect, The Principle of Balancing Test, Absolute Life Imprisonment, Relative Life Imprisonment, Human Dignity and Value, Misjudgment

www.kci.go.kr